

N. R.G. 784/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Dott. Giovanni CASELLA
Avv. Francesca BEONI
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere GA

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1971/23 est. Dott. Giorgio Mariani, posta in decisione all'udienza collegiale del 7/11/23 e promossa

DA

Parte_1 **(c.f.** C.F._1 **)**, residente in San Zenone di Lambro (MI) – Via Michelangelo n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ghirardi, come da mandato telematico allegato al fascicolo di primo grado con domicilio eletto presso il suo studio in Padova – Via Cristofori 1

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 **(P. Iva** P.IVA_1 **)**, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2, con sede in legale in Via Marco Valerio Corvo n. 171 – Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Pizzoferrato e Vincenza Paese del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, Via Durazzo n. 9 – 00195, giusta delega allegata alla memoria di costituzione di secondo grado ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123 n. 2001

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE come da ricorso in appello:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, Sezione Lavoro fissare l'udienza di discussione e, in riforma della sentenza n. 1971/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5 giugno 2023 e notificata in data 23 giugno 2023, che ha concluso il procedimento di primo grado pendente avanti al Tribunale di Milano – Giudice unico del Lavoro, RG 9119/2021, accogliere le seguenti conclusioni:

in via principale 1) Accertarsi e dichiararsi nei confronti della convenuta in nullità del licenziamento de quo, in quanto ritorsivo e/o discriminatorio;

2) Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n. 23/2015, condannarsi Controparte_1 con sede in Roma – via Marco Valerio Corvo n. 171 (P.IVA. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - con le medesime mansioni rispetto a quelle svolte precedentemente al licenziamento - e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, oppure nella diversa misura, o nella misura, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via subordinata:

3) Accertarsi e dichiararsi nei confronti della convenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento de quo, per l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore;

4) Conseguentemente, condannarsi Controparte_1 con sede in Roma – via Marco Valerio Corvo n. 171 (P.IVA. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ancora in via subordinata

5) Condannarsi Controparte_1 con sede in Roma – via Marco Valerio Corvo n. 171 (P.IVA. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;

In via di ulteriore subordine

6) Condannarsi Controparte_1 con sede in Roma – via Marco Valerio Corvo n. 171 (P.IVA. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2015, nonché al pagamento del preavviso contrattualmente previsto o nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti e onorari, e con distrazione a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario.

MEZZI ISTRUTTORI. Ai sensi degli artt. 346 e 437, comma 2, c.p.c., si ripongono le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, che per comodità della Corte si trascrivono in seguito.

Ordinarsi alla convenuta l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del LUL (Libro Unico), al fine di estrarne il nominativo dei testimoni.

Ove incomba al ricorrente e senza inversione del relativo onere, ammettere prova per testi contraria sulle istanze eventualmente dedotte ex adverso, nonché diretta sui seguenti capitoli di prova, nonché, ove occorra, su tutti i capitoli della parte in fatto del presente ricorso, preceduti da "vero che":

- omissis -

Si indicano come testi i sig.ri Persona_1 e Persona_2 .

PER LA APPELLATA come da memoria di costituzione:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per quanto esposto e motivato nelle premesse, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda d'appello formulata dal Sig. Parte_1 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 434 in quanto eccetto e 348 bis c.p.c.

In subordine ma sempre in via preliminare

-Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie riformulate per le motivazioni di cui al capo C. del presente atto

Nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento delle suindicate eccezioni preliminari:

- Rigettare integralmente la domanda proposta dal Sig. Parte_1 perché infondata sia in fatto che in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 1971/2023 emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. Lavoro – GdL Dott. Giorgio Mariani.

Con condanna dell'Appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Nella remota e denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati nella memoria difensiva di primo grado."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1971/23 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso proposto da **Pt_1** [...] - assunto da **Controparte_1** con mansioni di autista ed inquadramento nel livello G1 del CCNL per il settore logistica, trasporto merci e spedizione, dapprima in forza di un contratto a tempo determinato (8/8/19-7/9/19), successivamente rinnovato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato con lettera del 23/12/19 e licenziato per asserita giusta causa con comunicazione del 21/4/21, previa contestazione di addebito (assenza ingiustificata dall'1/4/21 al 12/4/21) con lettera del 13/4/21 - ricorso diretto ad ottenere la declaratoria di nullità, perché ritorsivo o discriminatorio o di illegittimità per insussistenza dell'addebito, del licenziamento de quo e la connessa tutela di cui all'art. 2 o in subordine di cui all'art. 3, 3^a comma o in ulteriore subordine di cui all'art. 3, 1^a comma o in via ulteriormente gradata di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 23/15.

Il giudice a quo preliminarmente rilevava che non potevano essere considerate le nuove argomentazioni formulate dalla difesa del ricorrente in sede di discussione - nello specifico (ii) *"la violazione dei termini di comunicazione della contestazione disciplinare e del licenziamento ex art. 32 CCNL (che stabilisce termini perentori, ai commi 7 e 9); ha eccepito l'assenza di un patto circa l'orario di lavoro del contratto part-time, in ragione della quale mancanza sarebbe stato impossibile contestare qualunque assenza se non prima di aver determinato (con un preavviso di 7 giorni ex art. 56 CCNL) l'orario concreto del lavoratore"* - che comportavano una mutatio libelli, dato che introducevano nel giudizio una causa petendi fondata su circostanze non prospettate prima.

Precisava, pertanto, che doveva essere esaminata solo la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., nel quale si era dedotto *"a) la giustificatezza dell'assenza del lavoratore, ritenendo quest'ultimo che fosse stato il datore di lavoro a ordinarli di non presentarsi più sul posto di lavoro; b) il fatto che il ricorrente abbia ripreso a lavorare in data 20 aprile 2020, circostanza ritenuta in contrasto con l'art. 2119 c.c., cioè con la valutazione della gravità del fatto che dovrebbe non consentire la "prosecuzione anche provvisoria" del rapporto."*

Tanto premesso, osservava che dalla documentazione versata in atti non si evinceva una chiara soluzione per accertare la fondatezza dell'addebito, mentre **CP_3**, responsabile dell'ufficio personale di **Controparte_1** che aveva presenziato all'incontro del 30/3/21, aveva confermato l'assunto di questa ultima *"...Il ricorrente ha chiesto specificamente che il suo contratto fosse trasformato in full-time o comunque l'assegnazione di servizi ulteriori rispetto a quelli che aveva, allo scopo di guadagnare di più. Il signor **Pt_2** ha riferito che, vista la situazione economica, non c'era possibilità di cambiare il servizio o il contratto. Inizialmente i toni erano cordiali. Successivamente, i toni si sono un po' alterati. **Pt_2** ha riferito che la situazione era quella e che se non gli andava bene ci sarebbero state altre aziende a sua disposizione. Nessuno ha suggerito a **Parte_1** di prendere ferie. Dopo il colloquio, **Parte_1** ha inviato un messaggio all'ufficio del personale e all'ufficio operativo, dicendo che se gli fosse successo qualcosa alla salute, il responsabile sarebbe stato **Pt_2** e l'azienda. Da quel giorno lì, **Parte_1** non si è più presentato sul posto di*

lavoro e non siamo più riusciti a contattarlo. Lo abbiamo chiamato sul cellulare ma il ricorrente rifiutava di rispondere. Dopo una settimana circa, ci è arrivata una mail da parte di **Pt_1** [...] in cui diceva che da fine marzo non era stato più chiamato a lavorare....”).

Evidenziava, dunque, come vi fosse **(vi)** “un significativo scarto temporale fra l’ultima richiesta di “servizio” di **Parte_1** (che è dello stesso giorno del colloquio con **Pt_2** 30 marzo 2021: doc. 7 fasc. ric.) e la richiesta del lavoratore di rientro (8 aprile 2021: doc. 8 fasc. ric.; doc. 19 fasc. conv.). Fra il 31 marzo 2021 (anzi: dal 1° aprile 2021, vista l’ “assenza del servizio” comunicata dall’azienda per il 31 marzo) e l’8 aprile 2021 vi sono quattro giorni lavorativi.

Ed è ragionevole ritenere che un lavoratore effettivamente interessato a lavorare non lasci passare questo tempo in attesa di una comunicazione, mentre potrebbe agevolmente recarsi presso l’azienda (intesa questa come luogo abituale di lavoro, in San Giuliano Milanese, e non come sede legale di **Controparte_1** che invece è in Roma) e rendersi così fisicamente presente sul luogo e all’ora in cui di solito inizia la sua prestazione (ore 5:30: doc. 30 fasc. **CP_1**).

Deve quindi potersi condividere l’asserzione di **Controparte_1** relativamente all’assenza ingiustificata del lavoratore, con conseguente rigetto di tutte le domande di quest’ultimo, visto che l’art. 32 del CCNL, alla lett. C) prevede che “...Il licenziamento disciplinare può essere adottato: - nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore” (doc. 34 fasc. **CP_1**).

(vii) Quanto all’altra questione, per cui il ricorrente aveva ripreso a lavorare in data 20 aprile 2020 (il giorno prima del licenziamento), circostanza ritenuta in contrasto con l’art. 2119 c.c., che esclude la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto, l’argomento pretende di provare troppo. La fattispecie dell’assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi “salvo i casi di forza maggiore” è tipizzata dall’art. 32, lett. C, del CCNL (doc. 34 fasc. conv.). Non si può quindi trarre da una provvisoria esecuzione del rapporto di lavoro prima del recesso alcun argomento sul difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare massima”

Parte_1 ha proposto appello, affidandosi a sette ordini di censure. **motivo (pag. 21 e seg.)** - “Contestazione del capo surriportato da pag. 8, ventinovesima riga, a pagina 9, sesta riga, e indicato come “**vi**” della sentenza gravata, relativo alla (asseritamente) ingiustificata assenza del lavoratore, per violazione dell’art. 416, comma 3, c.p.c. e per il fondarsi il convincimento del Giudicante su assunti privi di fondamento fattuale e probatorio, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c. per motivazione omessa e lacunosa” - si duole della violazione di legge e della errata valutazione di uno o più fatti centrali della controversia

Sostiene, in estrema sintesi, che, non essendo stato contestato da controparte il sistema in forza del quale “l’attività lavorativa era organizzata attraverso una chat “WhatsApp”, denominata “Operativo” (n. +393893149553 e +393404673781), con cui l’azienda comunicava al ricorrente - nelle ore serali del giorno precedente quello in cui doveva prestare servizio - i trasporti che doveva effettuare il giorno successivo” (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), non sussisteva alcuna assenza ingiustificata, dato che nei giorni oggetto della contestazione disciplinare nessuna richiesta gli era stata inviata e dunque egli era convinto in buona fede di non doversi presentare al lavoro : “È pacifico in atti (in quanto documentale e comunque non contestato), che in data 30.03.2021, poche ore dopo il “burrascoso incontro” (come definito dal Giudice di primo grado) tra il datore di lavoro e il lavoratore, quest’ultimo abbia inviato un messaggio WA (doc. 7, ricorso **Pt_1**) nella più volte menzionata chat aziendale denominata “Operativo”, chiedendo se dovesse recarsi o meno al lavoro il giorno successivo (31.03), ricevendo in risposta, solamente alle ore 23:04, il messaggio “domani niente servizio” da parte dell’azienda....

in assenza di tale esplicita richiesta, l'azienda nulla avrebbe comunicato al dipendente, dando per assodato che - in assenza di una sua comunicazione sulla chat ^{Orga} - questi non avrebbe dovuto presentarsi al lavoro il giorno successivo...

Riassumendo, l'addetta al personale della convenuta, dopo aver comunicato al ricorrente sulla chat WA aziendale, in data 30 marzo, che il giorno successivo non doveva recarsi al lavoro, qualche giorno dopo – invece di scrivere nuovamente sulla chat ^{Orga} lo avrebbe chiamato al telefono (ma della telefonata non v'è traccia in giudizio), per poi mandare una mail al legale dell'azienda, chiedendo se non fosse il caso di rivolgersi addirittura alla Questura."

Sostiene, altresì, che, a seguito dell'incontro del 30/3/21, egli era stato di fatto sospeso dalla azienda (la stessa teste intimata da parte appellata, CP_3 ha dichiarato che "il sig. Pt_2 ha riferito che la situazione era quella e che se non gli andava bene (al ricorrente, n.d.r.) ci sarebbero state altre aziende a sua disposizione" e pertanto "Una volta comunicato che la prestazione lavorativa doveva intendersi sospesa per quel giorno, era obbligo della ditta stessa, quantomeno ai sensi dell'art. 1375 c.c., attivarsi per "riattivare" la prestazione lavorativa del sig. Pt_1, comunicando quando si sarebbe dovuto presentare di nuovo in servizio."

Con il secondo motivo (pag. 40 e seg.) – "Ulteriore contestazione del capo surriportato da pag. 8, ventinovesima riga, a pagina 9, sesta riga, e indicato come "vi" della sentenza gravata, relativo alla ritenuta ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore, per violazione dell'art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604 e per il fondarsi il convincimento del Giudicante su assunti privi di fondamento fattuale e probatorio, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per motivazione omessa e lacunosa, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del CCNL per il settore Trasporti Industria" - denuncia la manifesta violazione di legge in relazione all'accertato superamento del periodo di assenza minimo (4 gg.) previsto dal CCNL del settore (precisamente dall'1 all'8 aprile del 2012).

Sostiene che: - i giorni lavorativi dal 1 al 7 Aprile 2021 sono quattro (giovedì 1, venerdì 2, martedì 6 e mercoledì 7), poiché lunedì 5 era lunedì dell'Angelo (ovvero "Pasquetta"), giorno pertanto non lavorativo;

- da questi quattro giorni lavorativi va tolto almeno un giorno settimanale in cui il lavoratore, assunto con contratto a part-time di 30 ore che rappresentano proporzionalmente anche meno di quattro giorni lavorativi, se comparati con l'orario normale di lavoro -, non avrebbe comunque dovuto lavorare.

Anche volendo considerare il sig. Pt_1 assente nei giorni indicati (pur così non essendo per i motivi indicati precedentemente), non erano comunque trascorsi i quattro giorni previsti dal CCNL prima che si il dipendente mettesse espressamente a disposizione, in data 08.04.2021."

Con il terzo motivo (pag. 42 e seg.) – "Contestazione del capo surriportato da pag. 9, settima riga, a pagina 9, quindicesima riga, e indicato come "vii" della sentenza gravata, relativo alla ritenuta irrilevanza della ripresa dell'attività lavorativa a partire dal 20.04.2021 per violazione dell'art. 2119 c.c. e per il fondarsi il convincimento del Giudicante su assunti privi di fondamento fattuale e probatorio, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per motivazione omessa e lacunosa." - lamenta la violazione di legge e la errata valutazione dei fatti di causa.

Ricorda di avere ripreso a lavorare il 20/4/21 (ovvero il giorno prima della lettera di licenziamento) a seguito di comunicazione aziendale e di avere svolto la prestazione regolarmente fino al 30/4/21:" Il fatto che il lavoratore sia stato riammesso in servizio dal 20 al 29 Aprile, dimostra comunque che il datore di lavoro non considerava la (asserita) assenza come sufficiente per ledere il rapporto fiduciario con lavoratore.....

Nella fattispecie in esame è nei fatti che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per la convenuta per almeno 10 giorni dopo il periodo contestato quale (asserita) assenza ingiustificata, il che è sufficiente a dimostra che non si trattava di una causa che impedisse la prosecuzione, “anche solo provvisoria”, del rapporto di lavoro.....

In via di assoluto subordine, il Giudice, anche in considerazione di quanto detto precedentemente in merito ai fatti che hanno condotto al licenziamento del ricorrente, avrebbe potuto, perlomeno, condannare l'azienda al pagamento del preavviso, così come previsto dal CCNL di settore”.

Con il quarto motivo (pag. 45 e seg.) – “Contestazione del capo surriportato da pag. 5, trentesima riga, a pagina 6, ottava riga, e indicato come “ii” della sentenza gravata, per violazione dell’art. 420, comma 3, c.p.c. e per il fondarsi il convincimento del Giudicante su assunti privi di fondamento fattuale e probatorio, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., nonché per motivazione omessa e lacunosa” - si duole della violazione di legge e della omessa/carente motivazione.

Ricorda che è onere del datore di lavoro dimostrare la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo che sorregge il licenziamento e di avere in sede di discussione evidenziato gli aspetti rimasti sforniti di prova o addirittura di allegazioni: “-non era stato dimostrato che il lavoratore dovesse presentarsi al lavoro nei giorni oggetto di contestazione, in quando non vi era indicazione della collocazione oraria in contratto, pur trattandosi di lavoro part-time, per cui l'assenza non poteva ritenersi sanzionabile;

- non era stato dimostrato il rispetto dei termini previsti dall’art. 32 del CCNL di settore per l'irrogazione della sanzione espulsiva (in particolare il termine di 20 giorni per l'invio della lettera di licenziamento)...

...non c'era alcun motivo di proporre alcuna mutatio (o anche solo una emendatio) libelli in relazione alla domande proposte nel ricorso introduttivo, poiché le osservazioni fatte in sede conclusionale riguardavano esclusivamente fatti e circostanze che incombeva a controparte dimostrare in giustizio e prova della giustificatezza del licenziamento, secondo quanto inequivocabilmente previsto dell’art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604...

Anche ammesso che si possa versare qui nell'ipotesi di emendatio libelli (e non certo di mutatio), il giudice ben avrebbe quindi potuto e dovuto esaminare le relative domande del ricorrente, anche se presentate in sede di conclusioni. Posto che non si è quindi verificata alcuna preclusione o decadenza sul punto, codesta Corte d'appello potrà ben esaminare i motivi sollevati dal ricorrente in corso di causa e decidere nel merito..”

Con il quinto motivo (pag. 51 e seg.) - “Contestazione del capo surriportato da pag. 5, trentesima riga, a pagina 6, ottava riga, e indicato come “ii” della sentenza gravata, per violazione dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 81/2015, dell’art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604, nonché per il fondarsi il convincimento del Giudicante su assunti privi di fondamento fattuale e probatorio, e per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., nonché per motivazione omessa e lacunosa” - denuncia violazione di legge e della normativa contrattuale collettiva,

Sostiene che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare non solo che nei giorni oggetto di contestazione disciplinare fosse assente senza giustificazione, ma preliminarmente che avesse l'obbligo giuridico di presentarsi, atteso che il contratto non conteneva alcuna indicazione della collocazione temporale della prestazione.

Osserva, inoltre, che “ il CCNL di settore (art. 56) prevede la possibilità di gestione flessibile del part-time solo in caso di patto scritto e sottoscritto avanti le OO.SS. (patto che, che nel caso in esame, non è mai stato sottoscritto): in questa ipotesi, comunque, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la variazione dell’orario con un preavviso minimo di almeno 7 giorni di calendario. Nel caso del sig. Pt_1 , l'azienda avrebbe dovuto, pertanto, prima di contestare l'assenza, indicare quali erano gli orari in cui, a suo avviso, il dipendente avrebbe dovuto prestare

servizio (con un congruo preavviso, che avrebbe potuto essere quello di 7 giorni previsto dal CCNL per l'ipotesi di cui si è detto) e solo dopo, eventualmente, contestargli l'assenza ingiustificata nei suddetti orari."

Con il sesto motivo (pag. 55 e seg.) - *"Contestazione del capo surriportato da pag. 5, trentesima riga, a pagina 6, ottava riga, e indicato come "ii" della sentenza gravata, per violazione, dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori nonché dell'art. 32 CCNL settore Trasporti (Industria) applicabile al rapporto di lavoro"* - lamenta violazione di legge e della normativa contrattuale collettiva.

Sostiene che il giudice a quo avrebbe dovuto esaminare per quanto sopra detto *" il motivo di ricorso relativo alla mancata allegazione da parte della convenuta, dei tagliandi di invio e ricevimento delle lettere di contestazione e di licenziamento, mancando così di fornire prova del rispetto detti termini indicati dal CCNL di settore per l'irrogazione delle sanzioni."*

Reitera in questa sede l'eccezione, poichè *"Nel produrre le lettere di contestazione disciplinare (doc. 23 e 28) e di licenziamento (doc. 32), però, la convenuta non ha prodotto i relativi tagliandi di invio e ricevimento (ed è ormai decaduta dal poterle produrre in giudizio), non consentendo così al Giudice di verificare il rispetto dei termini previsti dal CCNL che si sono indicati"*

Infine, con il settimo motivo (pag. 56 e seg.) - *"Si ripropone la domanda di reintegra e risarcimento del danno per licenziamenti discriminatorio e/o ritorsivo ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n. 23/2015"* - denuncia la omessa pronuncia sulla domanda di nullità del licenziamento perché discriminatorio e/o ritorsivo.

Sostiene di avere ampiamente dimostrato che l'iniziativa datoriale di recedere dal rapporto di lavoro è unicamente motivata *"dalle legittime richieste del lavoratore di regolarizzazione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto (da 30 a 35 ore, come riconosciuto anche dalla convenuta) al "burrascoso incontro" occorso in data 30.03.2021."*

Controparte_1 resiste in giudizio.

Preliminarmente eccepisce la inosservanza dell'art. 434 c.p.c., essendo il gravame eccessivamente prolisso, confusionario e ripetitivo e dell'art. 348 bis c.p.c. attesa la non ragionevole probabilità di accoglimento.

Eccepisce, inoltre, che *"l'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha articolato capitoli di prova non indicando in modo specifico i nominativi dei testi dei quali intendeva avvalersi, limitandosi ad indicare la genericità di tutti i dipendenti risultanti dal libro LUL della Org_2 ..*

il Giudicante ha, comunque, accolto le istanze istruttorie formulate dal lavoratore concedendogli la possibilità di indicare (tardivamente ed in sede d'udienza) ben due testi e, più precisamente, i Sigg.ri Per_1 e Per_2".

In ogni caso, osserva che *"l'istruttoria è stata compiutamente già espletata, anche se il contenzioso in parola risultava, comunque, già istruito attraverso la copiosa produzione documentale versata in atti dalla scrivente difesa.*

Le domande istruttorie che, oggi, controparte ripropone non sono state, infine, riproposte da parte avversa – come invece avrebbero dovuto essere – in sede di precisazione delle conclusioni."

Nel merito, replica alle singole censure di controparte, richiamando la difesa formulata in primo grado e difendendo la sentenza gravata.

Parte appellata produce inoltre due documenti a suo avviso fondamentali ai fini della decisione, con richiesta di ammissione: 1) modello unilav di cessazione del rapporto lavorativo; 2) comunicazione email (con relativi allegati) inoltrata in data 27/4/21 da *Controparte_1* al legale che la assisteva ed al consulente del lavoro nella quale si legge: *"...in allegato la lettera di licenziamento del Sig. Pt_1 che ha ritirato oggi in seguito a contestazione disciplinare per assenza ingiustificata superiore a 4 giorni consecutivi.*

Considera che questa mattina ha lavorato e nel primo pomeriggio ha ritirato la lettera, come da allegato. Resto a disposizione per chiarimenti ed in attesa dell'unilav. Grazie CP_4

All'udienza del 7/11/23, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

**Questioni preliminari*

Va disattesa l'eccezione sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 434 c.p.c., in quanto dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.

E la riproposizione da parte di Parte_1 della difesa svolta nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.

Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto; il legislatore ha solo statuito che *"i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente"*.

Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che *"l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"* (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).

Deve essere rigettata pure l'eccezione sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., perché non vi sono i presupposti per dichiarare il gravame, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.

Inammissibile è invece l'ulteriore documentazione offerta in visione da CP_1 [...] perché tardiva, oltre ad essere irrilevante ove diretta a confutare le nuove eccezioni/argomentazioni svolte dall'odierno appellante (vedi infra).

**Mutatio libelli (IV motivo)*

**Violazione dell'art. 5 del D.L.vo n. 81/05 e dell'art. 56 CCNL settore (V motivo)*

**Violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 e dell'art. 32 del CCNL settore (VI motivo)*

La doglianza inerente la limitazione della materia del contendere compiuta dal giudice di prime cure è priva di pregio.

Il ricorso ex art. 414 c.p.c. (pag. 8 e seg.) è incentrato sulla illegittimità del licenziamento per l'insussistenza del fatto contestato perché – come correttamente evidenziato dal giudice a quo – era stato il datore di lavoro *"a ordinare al ricorrente di non presentarsi più al lavoro dopo un diverbio occorso con il lavoratore in data 30.03.2020"* ; perché l'azienda nulla gli aveva comunicato tramite la chat Orga

per i giorni in contestazione e dunque egli riteneva in buona fede di non doversi presentare al lavoro; e perché aveva ripreso a svolgere la prestazione in data 20/4/21, dimostrando in tal modo il datore di lavoro *“di non aver subito alcun (eventuale e contestato) pregiudizio dall’assenza (anche laddove volesse essere considerata ingiustificata)”*.

E’ dunque evidente che l’introduzione, solamente nel corso della discussione, di nuovi, perché in precedenza non sollevati, profili di illegittimità del recesso impugnato - quali appunto, da un lato, la inosservanza dell’art. 5, 2^a comma del D.L.vo n. 81/05 che disciplina la collocazione oraria della prestazione nel part-time e dell’art. 56 del CCNL applicato che prevede un termine di preavviso nel caso di gestione flessibile del part-time; e dall’altro lato, la inosservanza dell’art. 7 della legge n. 300/70 e dell’art. 32 del CCNL applicato che regolamentano l’iter disciplinare - non potevano, né possono ora, trovare ingresso nel presente giudizio.

Pur se rimane invariata la tutela richiesta nelle rassegnate conclusioni (nelle quali, tra l’altro, sono invocati in via graduata i diversi rimedi stabiliti dal D.L.vo n. 23/15), muta la causa pretendi sottesa alla pretesa invalidità del licenziamento. Il Tribunale di Milano non ha pertanto, giustamente, esaminato le ulteriori eccezioni formulate tardivamente da Parte_1.

Ne consegue l’assorbimento dei motivi V e VI, con i quali il lavoratore lamenta l’omesso esame di dette questioni e ripropone le considerazioni svolte durante la discussione nel precedente grado di giudizio.

**Violazione dell’art. 2 del D.L.vo n. 23/15 (VII motivo)*

Il rilievo è condivisibile, non essendosi il Tribunale di Milano pronunciato al riguardo, ma la domanda principale proposta da Parte_1 non merita accoglimento.

Precisato che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. non vi è alcuna argomentazione a supporto della asserita natura discriminatoria del recesso impugnato, per quanto attiene alla pretesa natura ritorsiva si deduce che *“Ciò è stato dovuto (assenza contestata) alla legittima richiesta del ricorrente di avere delle risposte da parte dell’azienda in merito ai numerosi problemi insorti durante il rapporto di lavoro: in particolare, come detto, relativi all’orario di lavoro contrattuale inferiore rispetto a quello indicato nel primo contratto di assunzione, all’orario di lavoro effettivo di molto superiore a quello retribuito e al diploma Org_3 per il quale il ricorrente mai aveva sostenuto il relativo corso”*.

In appello (pag. 26) si ribadisce che *“La circostanza che, proprio la sera del 30 marzo, dopo il “burrascoso incontro” con il datore di lavoro, al lavoratore non sia stato assegnato alcun servizio dimostra, anche in via presuntiva ex art. 2727 c.p.c., che la decisione dell’azienda a seguito delle (legittime) rimozioni fatte dal ricorrente al titolare dell’azienda, fu quella di allontanare il lavoratore dal servizio, confermando quanto affermato dal ricorrente, ovvero che si tratta di un licenziamento discriminatorio e, o ritorsivo.”*

La giurisprudenza di legittimità è consolidata (cfr. Cass. n. 23702/23; conf. Cass. n. 6838/23; Cass. n. 26399/22; Cass. n. 26395/22; Cass. n. 21465/22) nell’affermare che, per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816/05; Cass. n. 3986/15; Cass. n. 9468/19), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni

causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555/11); e che dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 della legge n. 604/66, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742/18; Cass. n. 18283/10).

Ebbene, nella fattispecie concreta tale onere non può dirsi assolto, in considerazione: dell'attestato **Org_3** prodotto dalla attuale appellata (doc. 11), che dimostra la effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione; della deposizione resa da **CP_3**, la cui attendibilità non può essere messa in discussione solo per essere ancora in forza alla azienda, la quale ha "ridimensionato" la versione del lavoratore sulla portata dell'incontro del 30/3/21; ed altresì dell'impiego di **Parte_1** nel periodo successivo alle due contestazioni disciplinari.

**Sulla accertata sussistenza dell'addebito (I motivo)*

Parte_1 è stato destinatario di due contestazioni disciplinari (con lettera del 13/4/21 e con lettera del 16/4/21, doc. 13 e 14 ricorrente) sempre per assenza ingiustificata, ma il licenziamento in oggetto individua quale giusta causa la mancata presentazione al lavoro per il periodo dall'1/4/21 al 12/4/21 - periodo nel quale il Tribunale di Milano ha ravvisato la sussistenza dell'addebito per 4 giorni, precisamente il 1 che era un giovedì, il 2 che era un venerdì, il 6 che era un martedì ed il 7 che era un mercoledì) - per cui ininfluenza è la seconda contestazione, non richiamata nella lettera di licenziamento datata 21/4/21 (doc. 16 ricorrente).

E' nuova e perciò inammissibile la difesa svolta dall'odierno appellante sul computo del periodo minimo previsto dalla contrattazione collettiva (44 gg.) come assenza ingiustificata che andrebbe riparametrato al rapporto di lavoro part-time, eccezione di cui non vi è traccia nell'atto introduttivo del giudizio.

Tanto premesso, va ricordato che *"Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile."* (così Cass. n. 2988/11; conf. Cass. n. 16597/18; conf. Cass. n. 24698/22).

In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la censura coglie nel segno.

Risulta per tabulas che l'attività lavorativa dell'odierno appellante era gestita tramite la chat **Orga** attraverso la quale l'azienda gli comunicava giornalmente (di norma nelle ore serali) i viaggi e i trasporti che avrebbe dovuto effettuare il giorno successivo; che dopo la discussione del 30/3/21 il lavoratore ha inviato al datore di lavoro un messaggio sulla chat in questione, chiedendo che servizio avrebbe dovuto effettuare il giorno successivo, ricevendo la risposta *"domani nessun servizio"*; che da quel momento nessuna direttiva tramite detta applicazione è pervenuta all'autista nel lasso temporale in contestazione; infine che il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa a favore dell'azienda a far tempo dal 20/4/21 sempre tramite la chat WA utilizzata per inoltrare gli ordini di servizio.

Controparte_1 ha dedotto di avere cercato di contattare, nei giorni in questione, telefonicamente il lavoratore, che si sarebbe reso irreperibile - circostanze

contestate - e CP_3 ha confermato la versione della attuale appellata (*“Da quel giorno lì [30 marzo 2021], Parte_1 non si è più presentato sul posto di lavoro e non siamo più riusciti a contattarlo. Lo abbiamo chiamato sul cellulare ma il ricorrente rifiutava di rispondere. Dopo una settimana circa, ci è arrivata una mail da parte di Parte_1 in cui diceva che da fine marzo non era stato più chiamato a lavorare.”*).

Ciò nonostante, ad avviso del Collegio, la assenza dal lavoro non può ritenersi imputabile a Parte_1, appunto perché è assodato che nell'arco temporale di cui si discute nessuna indicazione gli sia pervenuta tramite il sistema usato per la organizzazione dei trasporti ed è perciò fondato l'assunto dell'odierno appellante di essere rimasto in attesa di ricevere direttive sulle consegne da effettuare successivamente alla (ultima) comunicazione datoriale del 30/3/20, con la quale gli era stato detto che il giorno successivo non avrebbe dovuto svolgere la prestazione.

L'addebito è pertanto insussistente, non essendo ravvisabile la assenza ingiustificata e, assorbito l'ulteriore motivo di gravame (III), in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la prima domanda subordinata fondata sull'art. 3, 2^a comma del D.L.vo n. 23/15, avendo la Suprema Corte chiarito che *“ai fini della pronuncia di cui all'articolo 3, comma 2, del Dlgs 23 del 2015, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ... comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”* (così Cass. n. 12174/15).

Previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 21/4/21, Controparte_1 va di conseguenza condannata a reintegrare Pt_1 [...] nel posto di lavoro ed a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari alla somma di € 1.747,98 (cfr. verbali di udienza del 21/2/22 e 12/4/22) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per quanto concerne l'aliunde perceptum da detrarsi, Parte_1 ha dichiarato all'udienza del 12/4/22 di avere nelle more trovato una occupazione, avendo lavorato come autista soccorritore dal 5/5/21 fino al 31/1/22 e di lavorare a termine per quel mese ad orario ridotto.

Le spese del doppio grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore della controversia, alla presenza o assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 1971/23 del Tribunale di Milano, dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 21/4/21, condanna Controparte_1 a reintegrare Parte_1 nel posto di lavoro ed a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma di € 1.747,98), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conferma la restante statuizione di merito.

Condanna *Controparte_1* alle spese del primo grado, che liquida in € 4.700,00 e del secondo grado, che liquida in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Milano, 7/11/23

IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani